

1503741-20.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) O afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal é medida de rigor. Com efeito, não há provas de que o estado de emergência sanitária tenha, de alguma forma, facilitado a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503741-20.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503741-20.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2309705/2020 - 1º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LIMA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

DAVID LIMA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 12 de dezembro de 2020, por volta das 18h, na Avenida Senador Feijó, nº 269, em Santos, o acusado tentou subtrair, para si, o celular Samsung J8, avaliado em R\$ 1.000,00, pertencente a Lucineia Brito da Silva Nascimento.

Apurou-se que, na data dos fatos, o réu ingressou na loja onde a vítima trabalhava, se passando por cliente. No momento em que a vítima se afastou e foi ao banheiro, o acusado pegou o celular dela, que se encontrava em cima da mesa, e colocou em sua cintura, porém foi avistado e detido na porta pelo dono do estabelecimento, e por populares que estavam perto do local dos fatos, impedindo, com isso, a consumação do delito. O bem foi encontrado junto ao denunciado e restituído a vítima.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de Ocorrência (fls. 02/04). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14).

A denúncia foi recebida em 16/12/2020 (fls. 59).

O acusado foi citado (fls. 88) e apresentou defesa prévia (fls. 96/97).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Sustentou que a materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do réu. Na dosimetria, na primeira fase, requereu o reconhecimento dos maus antecedentes. Na segunda fase, requereu a aplicação da agravante da prática do crime durante o estado de calamidade, a qual poderá ser compensada com a atenuante da confissão e também requereu que seja conhecida nessa etapa a reincidência do acusado, uma vez que possui condenação por roubo. Na terceira fase, requereu a redução pela tentativa em sua fração mínima, pois o réu percorreu grande parte do iter criminis, se apossando do celular da vítima e dando início a fuga, porém sendo detido antes mesmo de sair da loja, sendo assim deixando próximo a consumação do crime. Quanto ao regime de cumprimento da pena, requereu a aplicação do regime fechado, pois o réu não possui aptidão para o convívio em liberdade, já que é reincidente. Argumentou que é vedado ao acusado qualquer tipo de substituição da pena por restritiva de direitos.

A Defesa, em memoriais (fls. 195/199), argumentou que não há provas suficientes para ensejar o decreto condenatório. Alegou que o réu cometeu o delito por ato de desespero, tendo em vista as necessidades que sua família estava passando. Sustentou que há de se reconhecer a prática do crime impossível, pois o réu estava visivelmente drogado e abalado pela situação da sua família, chegando até mesmo a tropeçar ao tentar fugir da loja, por praticar o crime numa rua com alto fluxo de pessoas, sendo detido pelo dono do estabelecimento, de modo que não seria possível que ele cometesse o delito. Afirmou que o crime foi praticado na forma tentada, bem como o acusado confessou a prática delitiva, devendo esta ser reconhecida. Pugnou pela aplicação do previsto no Artigo 155, §2º, do Código Penal, devendo ser aplicada somente a pena de multa.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), bem como pela prova oral produzida durante toda a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A vítima, LUCINEIA BRITO DA SILVA NASCIMENTO, afirmou que avistou o réu pegando seu celular em cima da mesa. Por isso gritou, chamando atenção do dono do estabelecimento e este correu atrás do denunciado, que tropeçou em um degrau da loja, sendo assim detido por Mahamed e por populares. Seu aparelho foi recuperado. A polícia foi acionada. Não conhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha MAHAMED ABOU ARABI, dono do estabelecimento onde a vítima trabalha, disse que se recorda dos fatos e que eles ocorreram em seu estabelecimento. Afirmou que estava em sua sala, quando ouviu sua funcionária gritar e foi correndo em direção ao réu, que caiu devido ao espaço da loja, e foi detido na porta com ajuda de populares. Disse que segurou o denunciado até a chegada da polícia. Explicou que o celular estava com o réu e foi recuperado pela vítima. Afirmou que o acusado parecia estar sob efeito de drogas.

A testemunha DAVID SANTIAGO DOS SANTOS FERNANDES, policial militar, disse que foi acionado e quando chegou na loja o réu já estava detido. Disse que contaram para ele que o acusado entrou na loja e pediu água, quando a vítima entrou para pegar água, notou que ele havia subtraído o telefone. Narrou que após a tentativa de furto, o réu foi detido ainda no estabelecimento pelo dono e por populares. Aduziu que não se recorda se o réu foi levado à UPA Central. Reconheceu o acusado como o autor dos fatos. Disse que conhecia o acusado antes dos fatos.

O réu, DAVID LIMA DA SILVA, interrogado em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que se passou por comprador, e que ao perceber o celular em cima da mesa, o apanhou e colocou na cintura, foi em direção à saída, e foi detido. Alegou passar por necessidade e disse estar arrependido dos fatos.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos, e aos depoimentos colhidos durante a fase de instrução, verifico que a condenação do agente, quanto ao crime de furto, em sua modalidade tentada, restou plenamente comprovado.

O réu foi detido, pelo dono do estabelecimento onde a vítima trabalha, na posse do bem subtraído, no exato instante em que deixava o local do crime, restando, assim, demonstrada, de forma inequívoca, a sua responsabilidade penal.

As testemunhas de acusação foram uníssonas em seus depoimentos, dizendo que o denunciado foi visto pegando o celular da vítima, sendo detido na porta do estabelecimento onde ela trabalhava, enquanto tentava fugir, sendo que o aparelho celular da vítima se encontrava na cintura do acusado.

A testemunha Mahamed afirmou que correu em direção ao réu e, com ajuda de populares, o deteve. Sendo certo que o celular da vítima estava na cintura do acusado.

Já a testemunha David Santiago dos Santos Fernandes, policial militar, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que deteve no local dos fatos, corroborando, assim, a versão da testemunha Mahamed e da vítima.

A vítima também foi clara ao dizer que o acusado pegou o seu celular, que estava sobre a mesa, e tentou empreender em fuga, sendo detido pelo dono do estabelecimento e por populares, quando tentava fugir.

Assim, os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, e da vítima, são contundentes elementos de convicção, que respaldam a acusação acerca da prática do crime de furto pelo acusado, acrescentando-se, ainda, que este confessou a prática delitiva.

Ademais, a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, consiste, como se sabe, em elemento seguríssimo de convicção.

E, na hipótese dos autos, foi corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o manto do contraditório, restando demonstrado, portanto, que o acusado tentou subtrair o celular da vítima, não obtendo êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que foi detido no momento em que tentava fugir.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica a sua recusa". (JUTACRIM 93/239 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

"... não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão, levadas a efeito sob o crivo do contraditório. A confissão, de mais a mais, merece eficácia probatória porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilidade penal da recorrente ..." (TJSP, Apelação nº 0035628-85.2011.8.26.0577, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 5.10.2016). Além disso, nenhuma das testemunhas conhecia o réu antes dos fatos.

Some-se a isso o fato de o depoimento do policial militar ser coeso, fidedigno e ir ao encontro das outras provas colhidas nos autos, o que confere a ele grande credibilidade.

Por tudo isso, restou incontroverso que o réu foi detido no local dos fatos, com o celular que foi subtraído da vítima, não havendo dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito.

Contudo, o delito não se consumou, pois o réu foi detido ainda dentro da loja, onde a vítima trabalhava.

Com relação à agravante contida na alínea "j", inciso II, do artigo 61, do Código Penal, não é possível a sua aplicação, uma vez que a exasperação da pena nessa circunstância só é devida quando o agente se aproveita da situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação da calamidade pública para, assim, praticar o crime.

No caso em exame, não há qualquer prova de que o réu tenha se beneficiado da situação de calamidade pública vivenciada pelo país, para aumentar suas chances de sucesso na empreitada criminosa, não sendo o caso de aplicá-la de forma indistinta,

sem qualquer baliza.

Destaca, ainda, que o estabelecimento comercial estava funcionando, havendo funcionários trabalhando no local, o que impediu a consumação do crime de furto. A propósito, segundo Delmanto: "Por ocasião de calamidade pública, o Código Penal manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-a em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc." ("in" Código Penal Comentado, 9ª edição, São Paulo, Saraiva, p. 271).

Em mesmo sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) O afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal é medida de rigor. Com efeito, não há provas de que o estado de emergência sanitária tenha, de alguma forma, facilitado a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação." (TJ-SP - APR: 15182171720208260228 SP 1518217-17.2020.8.26.0228, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 20/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/04/2021).

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Afastada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Ausência de vinculação entre os fatos e o estado de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, sem influência na aritmética da pena." (TJSP; Apelação Criminal 1519970-09.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021). Grifei.

Diante do exposto, fica afastada a agravante contida na alínea "j", inciso II do artigo 61, do Código Penal.

Também deve ser afastada a alegação defensiva de crime impossível, haja vista que o fato de supostamente estar drogado em nada influenciou na prática criminosa, além da consumação do delito não ter sido efetivada pelo fato de réu ter caído durante a fuga, o que permitiu ser detido, de modo que a empreitada criminosa só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Também não há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado, figura prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal, tendo em vista que não se pode considerar o celular da vítima, como bem de pequeno valor, razão do próprio valor do objeto.

Por fim, anoto que o réu é reincidente.

Portanto, a condenação do acusado como incurso no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima.

Nessa esteira, observo que o réu ostenta maus antecedentes, conforme fls. 60/72 e 115/117. Portanto, aumento a pena base em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme documentos de fls. 60/72 e 115/117. Dessa forma, presente se faz a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Anoto, ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descrito na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal.

No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67 do Código Penal.

Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Assim, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

Desta forma, vale ressaltar trecho recente do V. Acórdão proferido no julgamento do HC 198395 AgR, pelo Ministro Alexandre de Moraes, em 08/04/2021: "Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão (RHC 118107, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011)".

Segue, assim, ementa do citado Acórdão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 198395 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)".

A respeito, seguem outras decisões do Supremo Tribunal Federal:

"Penal. Dosimetria. Concurso entre atenuante e agravante Art. 67, CP.

Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada". (HC 96061/MS, Segunda Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, DJE 02.04.2013).

"EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014).".

Neste sentido, também, tem entendimento o C. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA - RÉU RECALCITRANTE - ESCALADA COMPROVADA POR IDÔNEO LAUDO PERICIAL - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA À CONFISSÃO - EXEGESE DO ART. 67 DO CP - PRECEDENTE - NECESSIDADE DO REGIME FECHADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO APELO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0000100-57.2015.8.26.0574; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016)". Grifei.

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em 1/6 a pena fixada, somando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que, se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Portanto, diminuo a reprimenda pela metade, considerando para tanto o iter criminis percorrido pelo agente, tendo em vista que foi detido tão logo pegou o celular, dentro do estabelecimento, deixando evidente ter percorrido pelo menos metade do iter criminis, razão pela qual resta fixada a pena em definitivo, em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de conhecimento das condições econômicas do réu.

Fixo como regime inicial para o cumprimento da pena aplicada, considerando a reincidência do acusado, o semiaberto, observando os critérios norteadores do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, tampouco à suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, também do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o acusado, DAVID LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, visto que foi assistido por advogado dativo e lhe concedido os benefícios da gratuidade de justiça.

P.I.C.

Santos, 02 de março de 2021.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA